

RECURSO CÍVEL Nº 5026626-68.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: JOSE EDUARDO DOS SANTOS BASTOS (AUTOR)

ADVOGADO(A): EDWAR BARBOSA FELIX (OAB ES009056)

ADVOGADO(A): LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO (OAB ES010569)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 11 de dezembro de 2024.

5026626-68.2024.4.02.5001

500003474731 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5026626-68.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: JOSE EDUARDO DOS SANTOS BASTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação tributária que obrigue o autor a recolher imposto de renda (IR) sobre o Adicional de Hora de Repouso e Alimentação (AHRA) a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, bem como para condenar a recorrente a restituir os valores indevidamente recolhidos a esse título no quinquênio anterior à propositura da demanda.

A recorrente sustenta que a natureza indenizatória da parcela no âmbito trabalhista não se confunde com aquela prevista no âmbito tributário e que no regime de trabalho dos marítimos não há supressão de repouso e alimentação, mas concessão em momento posterior. Alega que a nomenclatura da parcela não se mostra suficiente para afastar a tributação, a qual deve incidir sempre que houver acréscimo patrimonial. Afirma que a incidência de IR sobre a AHRA é legítima tal como o é a incidência sobre a Indenização por Horas Trabalhadas (IHT), na forma reconhecida pela jurisprudência do STJ.

VOTO

A matéria controvertida nestes autos foi resolvida pela r. sentença recorrida com base na seguinte fundamentação:

"A Hora Repouso Alimentação - HRA é paga pelas empresas que demandam do empregado a supressão do intervalo intrajornada, tendo como consequência a exigência de pagamento de tal verba. De acordo com o art. 71, parágrafo 4º da CLT, quando o intervalo para repouso e alimentação não for concedido pelo empregador, ele ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho:

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas. (...)

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

A jurisprudência tradicional é desfavorável à pretensão do autor, senão vejamos:

(...)

Inclusive, recentemente, no julgamento dos Embargos de Divergência em REsp 1.619.117/BA, a Seção de Direito Público do STJ definiu que a verba denominada Hora Repouso Alimentação (HRA) possui natureza remuneratória. Confirma-se a ementa lavrada na ocasião, que contempla os fundamentos centrais prevalecentes:

(...)

Ocorre que a Lei nº 13.467/2017 alterou a redação do § 4º do art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho, que passou a estabelecer expressamente que "a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho".

Isso significa, que o legislador, assentou, ao menos pro futuro, o caráter indenizatório, por força de lei, de qualquer pagamento compensatório e ou relacionado à não concessão ou à concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, o que abrange a AHRA.

Assim, considero que, a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, não mais cabe a incidência de imposto de renda sobre a HRA, por não mais ser passível de figurar - por opção do legislador - como rendimento do trabalho."

Por prestigiar, a decisão recorrida, a clara opção normativa pondo fim à celeuma envolvendo a referida matéria no âmbito jurisprudencial, entendo que a r. sentença supra não merece reparos.

Com efeito, sabe-se que é garantido ao contribuinte o direito a um intervalo para repouso e alimentação durante sua jornada de trabalho, nos termos do art. 71 da CLT c/c a legislação específica (Lei n. 5.811/1972, no caso do petroleiro). Trata-se de **direito eminentemente trabalhista**, de ordem pública, o qual constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho.

Sem embargo, nas hipóteses em que **não há o efetivo gozo do direito** pelo trabalhador, o valor pago pelo empregador, por força de lei, em razão da não fruição do período possui evidente natureza de indenização, tal como **expressamente previu o legislador** ao editar a Lei n. 13.467/2017, que alterou o § 4º do art. 71 da CLT, o qual passou a dispor nos seguintes termos:

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

§ 4º - Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Incluído pela Lei nº 8.923, de 27.7.1994)

*§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, **de natureza indenizatória**, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)*

Ressalto que este Relator não ignora o fato de o tema dos autos - *incidência de IR sobre o AHRA (Lei n. 5.811/1972, art. 3º, II, e CLT, art. 71, § 4º)* - ser controvertido no âmbito da jurisprudência nacional, tal como se observa, inclusive, de decisões proferidas no âmbito das Turmas de Direito Público do STJ. Nesse sentido: REsp 1.328.326/BA, Primeira Turma, DJe 26.5.2017 (reconhecendo a natureza indenizatória da HRA); AgInt no REsp 1.727.114/BA, Segunda Turma, DJe 14.5.2019 (reconhecendo a natureza remuneratória da parcela).

Para mais, não desconheço que, no julgamento em EREsp 1.619.117, em 27.11.2019, a Primeira Seção do STJ objetivou pacificar a referida controvérsia, oportunidade na qual definiu, em sentido oposto ao ora defendido, que *"a HRA possui nítida natureza remuneratória, submetendo-se à tributação"* (EREsp 1619117/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 08/05/2020).

Sem embargo, é de se ressaltar que, naquele caso, o excelentíssimo Ministro Relator, Herman Benjamin, expressamente restringiu o objeto da tese fixada, assentando que *"A compreensão esposada abrange apenas os pagamentos e recolhimentos realizados **antes da entrada em vigor da Lei 13.467/2017**, uma vez que a nova redação do art. 71, § 4º, da CLT não foi objeto de discussão no presente caso."*

Ora, ainda que o excelentíssimo Ministro tenha justificado a não incidência da referida tese para o período posterior ao advento da Lei n. 13.467/2017 no argumento segundo o qual a questão não foi discutida naqueles autos, se procedessem quaisquer das alegações formuladas no recurso pela Fazenda - *a natureza indenizatória da parcela no âmbito trabalhista não se confunde com aquela prevista no âmbito tributário; no regime de trabalho dos marítimos não há supressão de repouso e alimentação, mas concessão em momento posterior; a nomenclatura da parcela não se mostra suficiente para afastar a tributação; há acréscimo*

patrimonial no hipótese; a incidência de IR sobre a AHRA é legítima tal como o é a incidência sobre a IHT, a despeito da inovação legislativa -, referida restrição não faria sentido, na medida em que o advento da inovação legislativa em nada alteraria o regime jurídico aplicável à espécie.

Ressalto que, apesar de a União alegar, sem nenhum apontamento concreto, que não houve supressão do intervalo para repouso e alimentação *in casu*, mas mera postergação da fruição, nos termos dos arts. 3º e 4º da Lei n. 5.811/1972, observo que os direitos previstos, respectivamente, pelos incisos V e II dos indigitados artigos **não decorrem da supressão do intervalo intrajornada**, constituindo, de todo modo, direito trabalhista autônomo daquela categoria especial de empregados. Posto de outra forma: nos termos do art. 2º, § 2º, da referida lei especial, o que indeniza a supressão do intervalo legal para o descanso e a alimentação do trabalhador é "*o pagamento previsto no item II do art. 3º*", e não os repousos previstos pelos arts. 3º, V, e 4º, II, da Lei n. 5.811/1972.

Ressalto, para os fins do art. 489, § 1º, VI, do CPC, que a par de os precedentes invocados pela parte não se referirem à rubrica discutida nesta ação, aqueles que o fazem cuidam da hipótese anterior ao EREsp 1619117/BA e/ou à Lei n. 13.467/2017. Mesmo AgInt no REsp 1.727.114 / BA, julgado em 2019, diz respeito a período anterior à reforma trabalhista.

Por fim, vale citar a tese firmada pela TNU em julgado recente pacificando o tema:

Tema 306 - "Com o advento da Lei nº 13.467, de 13/07/2017, que deu nova redação ao § 4º do art. 71 da CLT e estabeleceu expressamente a natureza indenizatória do pagamento operado pela supressão do intervalo intrajornada, habitualmente conhecido como Adicional Hora de Repouso e Alimentação (AHRA), em conformidade com a proteção constitucional à saúde do trabalhador (arts. 7º, XXII, 194, caput, 197 e 200, II, bem como art. 5º, § 2º c.c. arts. 4º e 5º da Convenção 155 da OIT, incorporada ao direito interno pelo Decreto n. 1.254/94, hoje consolidada no Decreto n. 10.088/2019 e o art. 7º, do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, incorporado ao direito interno pelo Decreto n. 591/92), não incide imposto de renda sobre a verba paga a tal título." (PEDILEF 0520381-15.2020.4.05.8400/RN, Acórdão Publicado em 09/12/2022)

Assim, reputo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

União isenta de custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001.

Por todo o exposto, **voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO** ao recurso da parte ré, nos termos da fundamentação supra.